

上帝不雇用同志？^{*} —— 雇主得否以宗教理由對同志差別待遇？

廖元豪^{**}

目次

壹、前言	由之可能——司法院釋
貳、憲法宗教自由之保障範圍與標準	字第490之曖昧態度
參、「禁止性傾向歧視」與「宗教自由」之衝突	二、美國法院之態度
一、中立法律有無違反宗教自	三、美國憲法判例值得借鏡之處
	肆、代結論：性別平等工作法之適用

* 謹以本文獻給愛主又安息主懷的吳庚老師。本文亦為科技部補助研究計畫「美國憲法上宗教自由、同性婚姻，與反歧視法之衝突」(105-2410-H-004-032-)之延伸研究成果。撰寫過程中，也感謝中研院博士後研究學者林榮光、清華大學物理學系王道維教授對此議題所提供的想法與各種回饋。
〔責任校對：陳怡瑾〕。

** 國立政治大學法學院副教授。
穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/03410102.pdf>。



「你們背起我的軛，跟我學罷！
因為我是良善心謙的：這樣你們必要找得你們靈魂的安息。」
(瑪竇福音11：29)

「那麼，凱撒的，就應歸還凱撒；天主的，就應歸還天主。」
(瑪竇福音22:21)

壹、前言

筆者在政大就讀博士班（1998-2000）期間，有幸修習、旁聽吳庚老師的課程。對於吳老師在課堂上的妙語如珠與才華洋溢，真是「雖不能至，心嚮往之」。每次聽吳老師講課或演說，都是一堂鮮美無比的學術饗宴。老師的眼神中，充滿了自信與熱愛學術的光芒，讓我們這些夢想從事學術工作的學生，也被他深深感染。他可以與學生激辯一節課，互不相讓，然後期末又給這個敢「捋虎鬚」的學生最高分。吳老師也是少數能夠旁徵博引「法律外」學術論述的法律學者。視野之廣，氣度之宏，學養之豐，光芒之銳，在在令學生難以忘懷。

然而，我卻是在吳老師的追思儀式中，才知道他是一位虔誠的天主教徒。或許是嚴守耶穌「凱撒歸凱撒，上帝歸上帝」的教訓，他在教授法律時，幾乎沒有提過聖經或其他天主教教義。他的立身行事，活出了耶穌的精神，做了最好的見證。

但在吳老師的法律學術生涯中，似乎還沒有碰到宗教與法律真正衝突、緊張的時刻。他所參與的司法院釋字第490號解釋，對於耶和華見證人的信仰與兵役義務的衝突，也是輕描淡寫地帶過。近來臺灣與歐美許多國家，關於「同性婚姻」與「宗教信仰」的對立衝突，恐怕是吳老師生前沒有預見的。作為一個研習憲法，又倡議

同性結婚權利的基督徒，我不禁也想：「如果吳老師在世，會怎麼看待這個問題？」這個議題，正需要有著吳老師這般心胸與眼界的學者來處理。如今吳老師已經安息主懷，我沒有請教他的機會。就讓後輩的我，以這篇文章，來追思紀念一代大師吳庚老師。

臺灣，如同世界各地，一直有著「宗教自由」與「同志權益」的緊張關係。尤其在反歧視法的領域，最容易發生衝突。一方面，法律規定禁止「性傾向歧視」；但同時憲法也保障人民的宗教自由不受法律過度限制。這二者之間，該如何求得雙贏？

我國雖不似基督教或伊斯蘭傳統深厚的國家，受到聖經中某些（看似）排斥同志的文字所影響¹，對同志的生活方式有特別的敏感性。但近年來由於同性婚姻合法化的爭議，仍然也看到不少宗教組織（特別是基督教相關團體）與同志運動的衝突。我國目前規範私領域的「反歧視法」主要仍僅限於「就業歧視」領域，而未及於一般的「公開交易場所」。其中最重要的「性別工作平等法」在2008年修正時，將「性傾向」納入禁止歧視的範圍。也使得「性別」的定義有所擴張：狹義的「性別」，係指男女；而廣義的「性別」，則包括「男女」以及「性傾向」。準此，任何雇主若以求職者或受僱人的性傾向而為差別待遇，就有可能抵觸性別工作平等法第二章的相關規定。

¹ 如：利未記18:22：你不可與男人同睡交合，像與女人同睡交合一樣，這是可憎的事；創世記19:1-11中，所多瑪和蛾摩拉城中的同性淫亂與強姦行為，遭到神的毀滅制裁；羅馬書1:26-27：為這緣故，神任憑他們放縱可羞恥的情慾。他們的女人，把順性的用處變為逆性的用處；男人也是如此，棄了與女人順性的交往，慾火攻心，男和男彼此貪戀行可羞恥的事，就在自己身上受這過失當得的刑罰；林後6:9-10：你們豈不知，不義的人不能承受神的國？不要被騙，無論是淫亂的、拜偶像的、姦淫的、作變童的、同性戀的、偷竊的、貪婪的、醉酒的、辱罵的、勒索的，都不能承受神的國。
至於這些經文是否代表了基督教精神必然排斥同性性傾向？教義上仍有爭辯餘地，但主流教會仍依字面解釋，所以多數基督教教會（含天主教）看待同志仍採「罪人」的態度。

然而，如果雇主是宗教團體，或形式上並非宗教團體，卻是基於宗教信仰之宗旨而設立之組織，若其教義本質上不能接受同志，則其對同志之差別待遇是否構成「性傾向歧視」？或是因為憲法保障其宗教信仰，性別工作平等法必須在此讓步？就如同天主教僅許男性擔任神職人員，但由於宗教自由之保障，這並不算是性別歧視。那性傾向的差別待遇呢？何種組織，能夠行使宗教自由而排除反歧視法的適用？

試想以下幾個虛擬案例：

【案例一】

某甲擔任台北市天主教榮光教會之神父，但後來公開出櫃表示自己是男同志，並且認為天主教應該改弦更張，容許女性與同志擔任神職人員。榮光教會遂依教義規定解除其職務。榮光教會之決定，是否牴觸性別工作平等法第11條第1項「雇主對受僱者之……解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇」之規定？

【案例二】

基督教教會設立之私立文文女中，一向以聖經與基督信仰作為品德教育的內涵，廣受好評。為維持此等傳統，其在招聘新任教師的公告上，特別註明「本校採高道德標準，專任教師之行為舉止應符合基督徒應有之精神，同性戀者請勿應徵」。請問文文女中此等徵才條件，是否牴觸性別工作平等法第7條第1項「雇主對求職者或受僱者之招募……不得因性別或性傾向而有差別待遇」的規定？

【案例三】

財團法人基督教善心基金會係以照顧受暴、失婚及其他無依婦女為宗旨之社福機構。今年開始提供員工「單身」與「家庭」宿舍，後者專供已婚夫妻租用。美美與花花均為善心基金會之員工，

也是一對女同志伴侶。由於司法院釋字第748號解釋宣告同性二人的婚姻自由應受憲法保障，就向基金會申請租用「家庭」宿舍。但基金會以其婚姻並非教會所認可的「婚姻」為由，拒絕出租，只能容許他們以較高的「單身」租金，入住。請問這是否牴觸性別工作平等法第9條「雇主為受僱者舉辦或提供各項福利措施，不得因性別或性傾向而有差別待遇」之規定？

處理此類爭議，必須在解釋、適用法律時，加入憲法精神的考量，方能做出適當的權衡。以下在本文第貳部分，就先析論憲法保障宗教自由之範圍與標準；第參部分參考美國有關「禁止性傾向歧視」之法律與憲法宗教自由衝突的案例；第肆部分則就我國應有之權衡標準提出建議，並試著解答前揭三個假設案例。

貳、憲法宗教自由之保障範圍與標準

憲法條文中，明文提及「宗教」並與宗教自由有關的條文有二：一是憲法第13條「人民有信仰宗教之自由」；另一個重要規定，則是憲法第7條「中華民國人民，無分……宗教……在法律上一律平等」。第13條的「宗教自由條款」，配上第7條的「宗教平等條款」，就是我國憲法有關宗教的主要規範基礎。

兩個條文配套起來，不但禁止國家任意侵害宗教自由；同時也禁止國家「因宗教因素」而課與負擔或賦予優惠。亦即，國家對宗教的「干預」與「分配」措施，都同時受到憲法的明文、特別約束。國家既不能罰，又不能賞，這自然就迫使國家在宗教事務上，必須採取消極、謙抑、中立的立場。可以說，「遠離宗教」是我國憲法對「國家與宗教」所採取的基本態度²。

2 廖元豪，從憲法宗教自由論宗教立法之原則，收於：宗教自由暨教義與國家法

或許也因為這個因素，雖然我國憲法並未明定「政教分離」，但大法官的解釋卻仍揭示出類似的觀念。在司法院釋字第460號解釋理由書、釋字第490號解釋文，以及較近的司法院釋字第573號解釋理由書，都出現這段闡釋憲法宗教自由意涵的文字：

……憲法第十三條規定人民有信仰宗教之自由，係指人民有信仰與不信仰任何宗教之自由，以及參與或不參與宗教活動之自由，國家不得對特定之宗教加以獎勵或禁制，或對人民特定信仰畀予優待或不利益。

至於憲法第13條所欲保障的內涵為何？大法官似乎目前仍未就宗教自由所欲保護的「法益」或「目的」，做清楚的闡釋。司法院釋字第490號解釋理由書有這樣一段：

內在信仰之自由，涉及思想、言論、信念及精神之層次，應受絕對之保障；其由之而派生之宗教行為之自由與宗教結社之自由，則可能涉及他人之自由與權利，甚至可能影響公共秩序、善良風俗、社會道德與社會責任，因此，僅能受相對之保障。

司法院釋字第490號解釋指出，宗教自由包含了宗教的「思想、言論、信念及精神」，還加上「派生之宗教行為」與「宗教結社」。但「言論」本來就是憲法第11條保障的權利；「結社」是憲法第14條保障之基本權利；「行為」則依司法院釋字第689號解釋，也是憲法第22條的「一般行為自由」之範圍。而「思想」、「信念」及「精神」，因為並未外顯，所謂「絕對之保障」也是理所當然（或是空話——政府法令如何管理內心？）。照這樣看，「宗教自由」豈不是一個多餘、重疊的條文？若從這個角度來看，那宗教自由之所以

經常被忽略，也是可以理解的了。

然而，宗教自由其實保障的是人性最根本，最基礎的「良知」(conscience)與「信念」(faith)³。吾人常云「人性尊嚴」，而人為什麼會有尊嚴？為什麼人性尊嚴值得保障？憲法預設了人會有良知，會有對世界、社會、人際的自主道德判斷，而這種價值預設的基礎，就是「宗教信仰的自由」⁴。世界第一部國家成文憲法——美國憲法——的制憲史也體現出，「宗教信仰自由」不是其他自由的重複規定，而是「第一自由」(first freedom)，是所有自由的基礎⁵。正因憲法承認每一個人都是能夠作成自主的道德、價值判斷之主體，才會導出其他的各種基本權利⁶。而這種自主擁有世界觀、生死觀、價值觀、社會圖像，並且依照自己相信的這套信念而行事，就是美國憲法所要保障的「自由行使宗教」(free exercise of religion)⁷！

依此，宗教自由要保障的是一個人最深層的信念與想法，以及根據此深層信念而展現出來的行為。這種行為乃是「自由行使宗教」與一般的行動、言論並不相同。因為它反映了個人的信念，而此一信念與個人本質身分認同密切相關，而不是單純表現偏好而已。

在這樣的理解下，才能填補司法院釋字第490號解釋沒有講清楚的部分——所謂「相對的保障」是到何種程度的「相對」？憲法上的基本權利本來就都可以在符合比例原則的情況下做一定的限

³ RONALD DWORKIN, RELIGION WITHOUT GOD 18-20 (2013).

⁴ Allen D. Hertzke, *A Madisonian Framework for Applying Constitutional Principles on Religion*, in RELIGIOUS FREEDOM IN AMERICA: CONSTITUTIONAL ROOTS AND CONTEMPORARY CHALLENGES 3, 9-10 (Allen D. Hertzke ed., 2015).

⁵ *Id.*

⁶ *Id.*

⁷ *Id.*

制，大法官並沒有具體說明，限制宗教自由的法律，是推定違憲或是推定合憲？司法院釋字第490號解釋雖然肯認「服兵役」的規定並不因為限制宗教自由而違憲，但「兵役」是憲法明文規定之義務，又涉及國家極為重大之利益，所以並不能依本號解釋率爾導出「法律可任意限制宗教自由之行使」之結論。相反的，若從前述宗教自由的「第一自由」性質作為基礎，那任何對「基於宗教信仰而出發之行為」加以限制之法律，均應受嚴格審查。

然而，從另一方面來說，性別工作平等法與其他反歧視法，也都是為了實現極為重要的公共價值。這兩種重要價值相互衝突時，應如何權衡處理？以下即探究主管機關與法院，處理此等問題應有之審查基準。

參、「禁止性傾向歧視」與「宗教自由」之衝突

一、中立法律有無違反宗教自由之可能——司法院釋字第490號解釋之曖昧態度

我國性別工作平等法第二章的「禁止性傾向歧視」規定，並沒有明文「針對宗教」，而是一般性適用的中立法律。然而，許多中立法律卻可能因為個別宗教信仰所在乎事項不同，而產生不同影響。例如，司法院釋字第490號解釋涉及的「兵役義務」對其他宗教的人，或許沒有直接影響；但對某些「絕對反戰」的教派（如：耶和華見證人，以及早期的基督教貴格會），就會產生特別的衝擊，使信徒必須在堅守信仰與接受刑罰之間擇一。那麼，憲法是否要求一般中立的法律，在適用時開一個「例外」，對於基於宗教信仰而為的行為，豁免其適用？或是這樣的法律會被宣告整個違憲？還是說，既然是宗教中立的法律，就沒有違憲的問題，而是宗教信徒必須自行承受信仰所需付出的代價？

初步看來，大法官在司法院釋字第490號解釋，似採否定說。面對耶和華見證人信徒的宗教自由主張，大法官除了闡釋宗教自由以禁止「宗教歧視」為原則外，較為具體之回應是：「……宗教之信仰者，既亦係國家之人民，其所應負對國家之基本義務與責任，並不得僅因宗教信仰之關係而免除……」以及

……上開條文，係為實踐國家目的及憲法上人民之基本義務而為之規定，原屬立法政策之考量，非為助長、促進或限制宗教而設，且無助長、促進或限制宗教之效果。復次，男子服兵役之義務，並無違反人性尊嚴亦未動搖憲法價值體系之基礎，且為大多數國家之法律所明定，更為保護人民，防衛國家之安全所必需，與憲法第七條平等原則及第十三條宗教信仰自由之保障，並無抵觸。（粗體為作者所強調）

從字面上推斷，大法官似以為，只要系爭法令沒有歧視宗教之目的或效果，就不涉及宗教自由的問題。但鑑於大法官的文字論述還是相當隱晦，我們未必能如此「腦補」地推論大法官全然否定「中立法律」（如：性別工作平等法之禁止性傾向歧視規定）有著構成侵害宗教自由之可能。

二、美國法院之態度⁸

美國最高法院對這個議題，也一再游移。早期曾採取絕對否定的見解。在 *Reynolds v. United States*⁹ 案中，對於摩門教教會（Mormon Church）肯認的「重婚」行為是否可豁免於重婚罪之規定，法院拒絕承認被告可以宗教自由為由而免責。最高法院並於判

⁸ 本節有關2015年以前判例之介紹，主要引自廖元豪，上帝高於凱撒？——宗教行為豁免於一般性法律規範的可能性，台灣法學雜誌，291期，頁58-62（2016年）。

⁹ See *Reynolds v. United States*, 98 U.S. 145 (1878).

決意見書表示：

若豁免此等行為，將使宗教信仰之教義高於國法，且使得每一個公民自己就成為法律。在這種情形下，政府名存實亡¹⁰。

但自從1963年起，最高法院改弦更張，對宗教自由給予更多的保護，對此種「對特定宗教造成嚴重負擔之一般法律」，採取較為嚴格之審查方式。1972年的*Wisconsin v. Yoder*¹¹是極有名的案例。*Yoder*案涉及的是威斯康辛州的「強迫入學法」(compulsory school attendance law，類似我國之「強迫入學條例」)與「老派阿曼門諾會」(Old Order Amish)的衝突。依據老派阿曼門諾會的教義，信徒與其子女應該避免受到外界、塵世的污染；但強迫入學法則要求父母必須讓16歲以下的子女就讀學校。當地的老派阿曼門諾會信徒只願意讓八年級以下的學童入學——因為超過這個年紀，就無法在老派阿曼門諾會當地的社區就讀，而必須出城去接受外界的污染！

最高法院採取利益權衡的途徑，表示州政府推動「普遍教育」(universal education)的目標雖然正當且重要，依然必須接受憲法檢驗，與老派阿曼門諾會的宗教自由權衡。而最高法院認定，要老派阿曼門諾會學童受八年級以上的學校教育，必然會對於其宗教信仰產生極大的不利衝擊；但州政府的利益，卻不見得會因為給予老派阿曼門諾會豁免而有重大影響——這些學童至少已經讀了八年。因此判決老派阿曼門諾會勝訴。

然而到了1990年的*Employment Division v. Smith*¹²，這個尊重宗

10 *Id.* at 167. 英文原文：“To permit this would be to make the professed doctrines of religious belief superior to the law of the land, and in effect to permit every citizen to become a law unto himself. Government could exist only in name under such circumstances.”

11 See *Wisconsin v. Yoder*, 406 U.S. 205 (1972).

12 See *Employment Div. v. Smith*, 494 U.S. 872 (1990).

教自由的趨勢又被翻轉過來。該案涉及某些美國原住民教會，一向在儀式中施打烏羽玉（peyote，一種由仙人掌粹取的藥物）的慣行。但這種藥品，依奧勒岡州（Oregon）州法，乃是一種管制藥物，除正當醫療用途外不得施打。原住民教會之成員因在宗教儀式中施打烏羽玉而被雇主免職，申請失業救濟卻遭拒絕。理由就是他們施打烏羽玉的行為，被認定為「行為不檢」（misconduct）。

最高法院不但拒絕承認施打烏羽玉可以豁免於奧勒岡州之管制藥品與失業救濟法，更根本上否定法院可以宗教自由為由而審查一般法律之適用。由Antonin Scalia大法官主筆的多數意見，限縮宗教自由之適用，認為唯有在法令措施特別「針對宗教」加以規範時，才有宗教自由的問題。任何人不能以宗教自由為名，要求免於一般法律的規範！此後，美國憲法宗教自由條款能夠發揮作用的空間，就變得相當有限；宗教團體與信徒，反而多用表現自由來捍衛權利。

有趣的是，美國最高法院在憲法上，對於審查「中立法律」大幅退卻之際，聯邦與各州的「立法」卻試圖在「恢復」宗教豁免於一般性法律的空間。尤其在「同志權益」或「同性婚姻」上，更產生了許多爭議。

爭議的背景是：當美國的同志平權運動，逐漸說服許多政治部門，通過「禁止性傾向歧視」的法律時，以基督教教會為主的宗教團體，均援引憲法宗教自由，或主張這些法律侵害其宗教自由，讓他們無法基於良心、信仰而拒斥同志（不雇用同志，不與同志交易等），係屬違憲；或主張宗教團體與組織應該可以豁免於這些法律的規定。

這一個問題的爭議，可追溯至前揭Smith案。依該判決之見解，若某個法令，並未明文針對宗教或特定宗教加以限制，那麼即使「附帶」限制了特定宗教，原則上不會被認定為「侵犯宗教自

由」。也就是說，宗教自由並不保障宗教行為有著「豁免於一般性法律規範」之地位。依此，若各州有著禁止「性傾向歧視」的法律，那基督教徒似乎無權主張基於教義信仰而排拒同志。

又由於*Smith*判決引起許多關切宗教自由的人強烈抨擊，美國國會更於1993年，立法通過「宗教自由恢復法」(The Religious Freedom Restoration Act of 1993, RFRA)，明文規定任何一般性法律，若對宗教造成「實質負擔」(substantial burden)，則僅在其乃追求極重要利益(compelling government interest)之必要措施時，方屬合法。雖然這個法律後來在*City of Boerne v. Flores*¹³被限縮範圍而僅能適用在聯邦政府而不及於各州州法，但各州也陸續通過類似法律。而聯邦國會也修法，在「宗教土地使用及機構法」(The Religious Land Use and Institutionalized Persons Act, RLUIPA)中，將RFRA的範圍擴張至任何受聯邦政府資金援助的單位。因此，到底宗教行為在何種條件下可豁免，還有著憲法與法律層次的拉鋸。

最高法院在2000年的*Boy Scouts of America v. Dale*¹⁴，又將此爭議複雜化。卻認定美國童軍團，得將出櫃之男同志童軍團長(Scoutmaster)予以除名。雖然紐澤西州(New Jersey)的反歧視法禁止性傾向歧視，但童軍團的結社自由，蘊含著它教導特定價值的自由，因此不得援引禁止性傾向歧視的規定，干預童軍團「除名出櫃同志」的決定。這個判決雖然不是明文基於宗教自由，但卻顯示各個團體、機構，可以基於(包括宗教在內的)其所信奉的價值，進而豁免於「禁止性傾向歧視」的法律。這也形同承認在*Smith*案之後，仍有「宗教行為豁免於一般性法律」的可能。

¹³ See *City of Boerne v. Flores*, 521 U.S. 507 (1997).

¹⁴ See *Boy Scouts of America v. Dale*, 530 U.S. 640 (2000).

2014年，聯邦最高法院在 *Burwell v. Hobby Lobby Store, Inc.* 案¹⁵，援引聯邦RFRA，將聯邦健康服務部「雇主應為員工投保包含『避孕給付』的健康保險」之規定，宣告其牴觸RFRA，不得適用於如 Hobby Lobby這種基於信仰而拒絕為員工投保的閉鎖性公司。本案雖未直接引用憲法宗教自由的規定，而是RFRA的法律層次爭議。但其將「宗教豁免」擴張至非宗教組織，甚至延伸到營利事業，也引起很大衝擊。

在2015年的 *Holt v. Hobbs*¹⁶，聯邦最高法院則全體一致援引 RLUIPA，認定阿肯色州（Arkansas）監獄中的「禁止蓄鬚」政策，適用在基於伊斯蘭信仰而堅持蓄短鬚之受刑人，係屬違法。

從以上的判例來看，*Smith*所揭示的「中立原則」是否仍能維持？是否應該維持？宗教信仰自由若全然必須服從一般性法律，那是否太過忽視宗教信仰的特殊性與「非世俗性」？如前所述，美國最高法院以往曾經在判例中，宣告老派阿曼門諾會的學生家長，得基於宗教自由有限度拒絕受強迫教育（*Wisconsin v. Yoder*）；也曾判決耶和華見證人學生，有權基於表現自由（但骨子裡是宗教信仰）而拒絕向國旗敬禮（*West Virginia State Board of Education v. Barnette*）¹⁷。這些都是膾炙人口的判例。而美國國會與各州的立法，除了RFRA外，各種反歧視法往往也賦予宗教組織某種程度的「豁免權」¹⁸，只是範圍有多大？宗教信仰自由、一般性的法律政策，與他人免於歧視的自由，到底該如何權衡？這在同志權益逐漸

¹⁵ See *Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.*, 134 S. Ct. 2751 (2014).

¹⁶ See *Holt v. Hobbs*, 135 S. Ct. 853 (2015).

¹⁷ See *West Virginia State Bd. of Educ. v. Barnette*, 319 U.S. 624 (1943).

¹⁸ E.g. 42 U.S.C. § 2000e-1 (2020). (This subchapter shall not apply to...a religious corporation, association, educational institution, or society with respect to the employment of individuals of a particular religion to perform work connected with the carrying on by such corporation, association, educational institution, or society of its activities.)

受到重視，尤其是同性婚姻被承認後，會愈發嚴重。(種族、性別歧視也有類似的問題，但基督教與同性婚姻的直接衝突較大。因此「禁止種族歧視」只是限制了他人的偏好，但「禁止性傾向歧視」很可能就會碰觸到許多基督徒的宗教價值觀)。

在 *Obergefell v. Hodges* 案¹⁹ 承認同性婚姻受憲法保障後，立即產生進一步爭議。部分基督教團體在各州倡議牧師拒絕為同志伴侶證婚的行動，某些外燴、花店、婚禮設計等業者，也表示基於宗教因素不願意與同性婚姻的婚禮締約。甚至有政府官員，以個人宗教信仰為由，拒絕核發同志「結婚證書」。雖然目前遭法院判處藐視法庭，並遭拘留處罰，但也顯示這個議題的爭議性²⁰。就算是私領域行為，這是否屬於單純的契約自由，由民事關係處理即可？核心的宗教團體在「證婚」等儀式上，如此主張或許比較容易被接受。但非宗教團體（如前述的 *Hobby Lobby*）主張此等「拒絕交易」的正當性何在？

2018 年的 *Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission*²¹ 是最高法院在同性婚姻合法化之後，第一次面對此等爭議。*Masterpiece Cakeshop* 是由 Jack Phillips 這專業烘焙師所擁有並經營的烘焙店，位於科羅拉多州（Colorado）。Phillips 同時也是虔誠的基督徒。在 2012 年，一對同性伴侶想要在已經承認同性婚姻的麻州結婚（當時，科羅拉多尚未開放同性婚姻），並且請 Phillips 為婚禮訂做蛋糕。但 Phillips 基於信仰因素，表示不能祝福、慶賀這

19 See *Obergefell v. Hodges*, 135 S. Ct. 2584 (2015).

20 See Steve Bittenbender, *Contempt Ruling Upheld Against Kentucky Clerk Against Gay Marriage*, REUTERS (July 14, 2016), <https://www.reuters.com/article/us-kentucky-lgbt-idUSKCN0ZT2NU>. (肯塔基州（Kentucky）一名負責核發結婚證書的官員 Kim Davis，宣稱同性婚姻抵觸其宗教信仰，拒絕依法對同性伴侶核發結婚證書。聯邦地方法院命令其依法核發，Davis 仍拒絕服從。法院遂判處 Davis「藐視法庭」，並將其拘禁。其職務代理人對原告核發結婚證書後，Davis 方被釋放。)

21 See *Masterpiece Cakeshop v. Colo. Civil Rights Commission*, 138 S. Ct. 1719 (2018).

種聖經所不接受，州法也尚未承認的「婚姻」，所以拒絕訂做蛋糕²²。

這樣的「拒絕交易」，涉嫌違反該州的反歧視法（Colorado Anti-Discrimination Act (CADA)）。依據CADA，公開販售與提供服務的店面，不得有「性傾向」歧視。該州之民權委員會經過審議，認定其違法，並命其停止並改善其歧視行為²³。Phillips雖然提出「宗教自由」之抗辯，但州政府與州法院均援引前揭*Smith*案，認為宗教自由並不賦予任何人「豁免於中立法律之權利」²⁴。

案件上訴至聯邦最高法院，多數意見一方面承認「禁止歧視」的原則必須被遵守，但也同時要求政府在權衡宗教自由時，不得具有敵意。由Anthony Kennedy大法官主筆的多數意見書指出，同志與同性配偶的平等自由，必須被法院尊重並給予高度重視²⁵，反歧視法應該充分執行。然而，Phillips並非要求將CADA宣告違憲，而只是指出個人良心、信仰，以及表現自由（製作蛋糕表達祝賀訊息），在這個案件將受到壓縮。何況科羅拉多州當時還沒有承認同性婚姻，聯邦最高法院也尚未判決認定同性婚姻受到憲法保障，因此他當時「不承認同性婚姻」也是合理的²⁶。此外，州政府之前曾在3個案件中，認定烘焙店可以基於自己的信念，拒絕製作「貶抑同志或同性婚姻」的蛋糕裝飾。所以，即使是執行（宗教中立的）CADA，州政府以往是可能允許店家，依信念理念而拒絕服務的²⁷。

²² *Id.* at 1724.

²³ *Id.* at 1725-26.

²⁴ *Id.* at 1726-27.

²⁵ *Id.* at 1727.

²⁶ *Id.* at 1728.

²⁷ *Id.* at 1728-29.

更重要的，是法院從事證資料中發現州政府的民權委員會在審議時，並未謹守「中立」原則，而多處展現了對宗教信仰的「敵意」。某位委員曾於會議中，表示Phillips可以信仰宗教，但如果要在本州做生意，就不能依據宗教信仰行事。最高法院認為這種負面評語，顯示其對宗教自由權利，及當事人在此種事件上的兩難，欠缺考慮。另一位委員更在會議中發言認為「宗教自由與宗教，在歷史上都被用來正當化所有的歧視行為，包括奴隸制度、納粹大屠殺」「我們能列出上百種例子，都說明宗教自由都被拿來為歧視背書。而且，對我來說，這是人們用來正當化歧視時，最卑劣的藉口——用宗教去傷害他人。」（“[W]e can list hundreds of situations where freedom of religion has been used to justify discrimination. And to me it is one of the most despicable pieces of rhetoric that people can use to—to use their religion to hurt others.”）²⁸

這段話雖然只是某位委員的發言，但其他委員並無異議也沒有表示任何意見，甚至在上訴過程中都沒有與此論點保持距離。就此而言，最高法院認為極為嚴重。因為若將一個人的信仰，說成是「最卑劣的藉口」，那就是在兩方面貶抑宗教：卑劣、藉口。依據先例，政府在處理有關宗教自由爭議時，必須謹守中立——立法上與行政上的中立。而從委員會的紀錄上，該委員會對Phillips的宗教異議，既不容忍也不尊重。尤其與之前州政府特別給予店家「拒絕製作貶抑同志之蛋糕裝飾」的案例來比較，更看出其未以中立（不敵視）的態度來權衡本案當事人的宗教信仰與反歧視法之間的衝突，因此違反宗教自由，其對Phillips的處分以及下級法院之判決應予撤銷²⁹。

²⁸ *Id.* at 1729.

²⁹ *Id.* at 1732.

三、美國憲法判例值得借鏡之處

從美國聯邦最高法院的判例觀之，其對「中立法律」（包括反歧視法）是否應對宗教自由讓步，為其開例外，一直在游移擺盪。近年來愈來愈多學術著作，批評政府與法院過於講究「形式中立」與「世俗/宗教」組織的二分法，而忽視宗教自由可能因為一般性法律而遭到壓縮的事實³⁰。也有學者指出，宗教自由與一般中立法律之執行，其實在大多數情況，都可以取得雙贏³¹。重點在於法院是否認真地權衡各方利益，並且思索「宗教豁免」是否為必要的保護措施。

雖然在*Smith*案之後，「宗教中立」的一般性法律，包括「禁止性傾向歧視」的反歧視法，原則上都不會被認定違憲侵犯宗教自由——即使對某些宗教信徒可能造成特別嚴重的負擔。但從RFRA的幾個案例，以及最近的*Masterpiece Cakeshop*案，也可以看出聯邦最高法院開始注意到，宗教信仰應該擁有更多「免於一般性法律之侵害」的空間；「中立論」可能在事實上會對宗教信仰造成不必要的壓抑。以*Masterpiece Cakeshop*而言，其更開啟日後個案權衡的空間。即使不能導出全面的「宗教自由豁免」，至少也在個案中顯示出，基於宗教信念而為的「行為」未必能被定位為「歧視」。

而若採取「權衡」的方法，那「宗教自由」與「免於歧視」的利益要如何權衡，就必須注意脈絡。例如，若反歧視法所規範的是「一般公開交易」，那給予宗教自由一些「豁免」空間，或許不會造成太大傷害。因為在一個充分競爭的市場下，特定賣家的「拒絕交易」或「拒絕提供服務」，對同志的商業利益與尊嚴，傷害有限。

30 See STEPHEN V. MONSMA & STANLEY W. CARLSON-THIES, *FREE TO SERVE: PROTECTING THE RELIGIOUS FREEDOM OF FAITH-BASED ORGANIZATIONS* (2015).

31 See FRANK S. RAVITCH, *FREEDOM'S EDGE: RELIGIOUS FREEDOM, SEXUAL FREEDOM, AND THE FUTURE OF AMERICA* (2016).

這一家蛋糕店不肯訂做蛋糕，別家店還是可以。甚至也許有些店家還可以「專門製作同性婚禮糕點」作為競爭手段。可是，如果是「就業歧視」，除非雇主是核心的宗教團體或以宗教誠命為組織目標的團體，否則似應多負擔一些公共責任，以免傷害同志的就業權利。

上述案例中，嚴格來說，涉及性傾向歧視與宗教自由衝突的「就業歧視」只有一例——*Boy Scout of America*，但法院在形式上是以「結社自由」為依據。另外，*Hobby Lobby*亦是涉及雇主義務的案子，不過與歧視較無關係，且受僱者依然可由其他方法獲得避孕保險給付。

本文以為，「就業」與一般、單純的「交易」不同，在此領域的「拒絕雇用」（或不利差別待遇）對同志侵害較大。應限縮於最核心的宗教組織，或是直接以實現信仰為目的的單位，方可享受「宗教自由」。而若為一般商業組織，或是立案宗旨與信仰並無直接關係的非營利組織，那原則上仍應受「禁止歧視」的誠命所規範。

肆、代結論：性別平等工作法之適用

前述檢討美國憲法判例而得出的原則，在我國似應可參照。畢竟，宗教自由是中華民國憲法之明文規定，而性別工作平等法亦屬一般性適用的法律，其目的在保障任何人不因其性傾向而在就業領域遭受排擠貶抑。或謂我國社會與政治之基督教色彩並不那麼強烈，但這不應該是「宗教自由受較少保護」的理由。相反地，正因為宗教，尤其是基督教人口數量在我國並不似美國那麼大，即使給予某種彈性或豁免，對整體法律秩序的衝擊也很小。

準此，本文以為，在【案例一】，天主教榮光教會解僱公開出櫃男同志之神父，應受宗教自由之保障，而不構成性別工作平等法第11條之「性傾向歧視」。「教會」當然是最核心的宗教團體，受到最強烈的宗教自由之保障。神職人員的任用，本來就要絕對符合宗教教義的標準。雖然性別工作平等法第7條但書僅對「性別」，有「工作性質」之例外規定（對「性傾向」似無此等例外），但解釋上如系爭工作（神職人員）本來就不適合公開出櫃男同志擔任，那也應該以合憲性解釋之方式，限縮第11條規定之適用或是依「阻卻違法」的法理，不予以處罰。

在【案例二】的爭議則較大。一方面，私立學校即使是教會所設立，但仍為「世俗組織」，與前例之教會仍有不同。另一方面，宗教團體所設置的世俗組織，仍然可能是以實踐教義與宗教誠命為目的。在這種情形下，各種法令措施是否得要求其為符合世俗法律之公益，而放棄、妥協其信仰？

這個問題會變得複雜，還牽扯到我國的教育法規，一向沒有細緻區分公立與私立學校，忽視私立學校教育應該有著較大的自由空間，以體現教育多樣性與私人辦學的不同理念³²，也沒有考量私立學校其實是人民可以自行選擇是否就讀的——所以少有「強迫」的性質。私立學校法第7條甚至規定非宗教研修學院的私立學校，不得強制學生參加任何宗教儀式或修習宗教課程，基本上就否定了「以宗教信仰作為教育之一環」的可能。

在我看來，本案例中的私立文文女中，仍應遵守性別工作平等法第7條「禁止性傾向差別待遇」的規定。因為即使以基督教或道德觀點而論，同志（公告上寫「同性戀」）身分的人，也並不必然

32 廖元豪，與眾不同，抑或一視同仁？——多元文化教育、自由主義，與平等權之關係，收於：國立政治大學法學院公法學中心編，公法研究的世代對話：法治斌教授逝世十週年紀念論文集，頁137-138（2013年）。

不適合當「教師」。聘任同志擔任教師，並不當然破壞私立文文女中的教育任務。文文女中甚至沒有明文要求應徵者必須是基督徒，而僅要求「符合基督徒應有之精神」；那又為何全然排斥同志？即使是同志，在行為舉止或是教育風格上，依然可以「以聖經與基督信仰作為品德教育的內涵」。

至於【案例三】，既然基督教善心基金會並不排斥僱用同志擔任員工，而同志員工也可以租用宿舍，可見同志身分與基金會的「功能」或「宗旨」並無衝突。

雖然基督教的主流見解，並未承認同性婚姻。但同性婚姻如屬國家法律所保障之制度，則基督教善心基金會提供「家庭宿舍」並不會被人誤解為「基督教已經改變教義，承認同性婚姻」。該基金會只需要單純的「適用國家法令」而給予「異性配偶」和「同性配偶」相同的保障即可。

有鑑於此，本文以為，在立法院依據司法院釋字第748號解釋之意旨，制定「司法院釋字第七四八號解釋施行法」之後；或是在2019年5月24日大法官所宣告的「最後通牒日」（同志可登記結婚）之後，本案中的基督教善心基金會就不得拒絕給予同性配偶「家庭宿舍」。但在此之前，由於我國法律尚未正式落實同性「婚姻」，基金會不承認同性伴侶為「配偶」，尚不違法。

參考文獻

1. 中文部分

廖元豪（2010），從憲法宗教自由論宗教立法之原則，收於：宗教自由暨教義與國家法制之規範論壇編輯委員會編，宗教自由暨教義與國家法制之規範論壇論文集，頁111-163，臺北：銘傳大學法律學院/財團法人台北市教會聚會所。

——（2013），與眾不同，抑或一視同仁？——多元文化教育、自由主義，與平等權之關係，收於：國立政治大學法學院公法學中心編，公法研究的世代對話：法治斌教授逝世十週年紀念論文集，頁101-144，臺北：新學林。

——（2016），上帝高於凱撒？——宗教行為豁免於一般性法律規範的可能性，台灣法學雜誌，291期，頁58-64。

2. 外文部分

Dworkin, Ronald. 2013. *Religion without God*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hertzke, Allen D. 2015. A Madisonian Framework for Applying Constitutional Principles on Religion. Pp. 3-32 in *Religious Freedom in America: Constitutional Roots and Contemporary Challenges*, edited by Allen D. Hertzke. Norman, OK: Oklahoma University Press.

Monsma, Stephen V., and Stanley W. Carlson-Thies. 2015. *Free to Serve: Protecting the Religious Freedom of Faith-Based Organizations*. Michigan, MI: Brazos Press.

Ravitch, Frank S. 2016. *Freedom's Edge: Religious Freedom, Sexual Freedom, and the Future of America*. New York, NY: Cambridge University Press.